

1502291-26.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Jardim América, Sertãozinho - SP -
cep 14160-260

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502291-26.2021.8.26.0530

Controle: 2021/002187

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2277474/2021 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 20762272 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2702/21/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2277474 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2277474 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 2702/21/907 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR ISAAC DE OLIVEIRA

Aos 16 dias do mês de Agosto de 2022, às 14:40 horas, foi aberta a audiência, nos autos da ação supra referida realizada por meio virtual semipresencial, através do aplicativo Teams. Aberta com as formalidades legais, foram apregoadas as partes que participaram da videoconferência. A gravação será disponibilizada no sistema informatizado SAJ-PG5, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Pelas partes foi manifestada concordância para que as gravações fossem feitas de forma individualizada, em arquivos separados de acordo com o número de testemunhas, visando facilitar futuros acessos. Sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. ANGEL TOMAS CASTROVIEJO, comigo Escrevente abaixo assinado, COMPARECERAM de forma virtual através do aplicativo TEAMS o Promotor de Justiça, Dr. DANIEL TOSTA DE FREITAS; o réu VITOR ISAAC DE OLIVEIRA; o Defensor substabelecido fls. 147, Dr. CARLOS EDUARDO SERRANO SANCHES, (OAB/SP 444409) e a estagiária PRISCILA MONTEIRO; COMPARECERAM presencialmente ao prédio do fórum desta comarca: as testemunhas arroladas pela acusação CRISTIANO DE JESUS e FABIO AUGUSTO DA SILVA SOUZA. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz inquiriu as testemunhas arroladas pela acusação CRISTIANO DE JESUS e FABIO AUGUSTO DA SILVA SOUZA, todas

qualificadas em videoconferência; pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. A seguir o MM. Juiz interrogou o réu VITOR ISAAC DE OLIVEIRA. Após, não havendo outras provas a serem produzidas, o MM Juiz declarou encerrada a instrução processual e passou aos debates orais, dando a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e à Defesa. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação de teleaudiência, por meio do aplicativo Teams, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Pelas parte foi manifestada concordância para que as gravações fossem feitas de forma individualizada, em arquivos separados de acordo com o número de testemunhas, visando facilitar futuros acessos. A seguir pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA:

"Vistos.

VITOR ISAAC DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 9 de outubro de 2021, por volta das 17h00, na rua Francisco Amêndola nº 566, Conjunto Habitacional Ulysses Guimarães, nesta cidade e comarca, mantinha em depósito e trazia consigo, respectivamente, 02,05g (dois gramas e cinco centigramas) de Cocaína em pó, acondicionados em 11 (onze) microtubos plásticos do tipo eppendorf, e 10,15g (dez gramas e quinze centigramas) de Maconha, divididos em 11 (onze) porções, para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, Vitor estava em local conhecido como ponto de venda de drogas, trazendo consigo 11 (onze) porções de Maconha, quando dispensou um objeto ao chão. Diante da conduta do acusado, guardas civis municipais que patrulhavam na região resolveram abordá-lo em constatarem a posse de 11(onze) porções de Maconha pelo increpado, além da quantia de R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). Os guardas civis ainda puderam localizar em uma arquibancada próxima ao réu, mais 11 (onze) pinos de Cocaína, os quais foram apontados por Vitor aos agentes públicos. Indagado a respeito, o acusado confessou informalmente aos guardas municipais que estava pelo local praticando o tráfico de drogas, desde às 08h00 da manhã.

A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2021 (fls. 82/83), o réu foi citado (fls. 116) e apresentou defesa prévia (fls. 120/122).

Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa do réu, por sua vez, requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pugnou pela fixação de penas mínimas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além de regime aberto.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), pelos boletins de ocorrência (fls. 04/05 e 28/29), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18), pelas imagens fotográficas (fls. 19, 20, 21 e 22), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 23), pelos exames químico-toxicológicos (fls. 68/70 e 71/73), conclusivos por se tratar de Cocaína e Maconha, respectivamente, e pela prova oral colhida.

A autoria também é indubitável.

Os guardas civis municipais Cristiano e Fábio, na fase policial, disseram que durante patrulhamento de rotina, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, avistaram Vitor em atitude suspeita, uma vez que dispensou um objeto ao chão. Em razão disso, o abordaram, sendo encontrado com ele 11 (onze) porções de Maconha, bem como R\$ 225,00 (duzentos e cinquenta reais). Narraram que na arquibancada em que o réu estava próximo, encontraram, após ser apontado por Vitor, mais 11 (onze) pinos de Cocaína, cuja propriedade foi, ali, assumida por ele. Durante a abordagem,

Vitor confessou que estava ali exercendo o comércio de entorpecentes desde às 08h00 da manhã, razão pela qual conduziram-no ao plantão policial (fls. 06/07).

Em Juízo, confirmaram que, em patrulhamento de rotina, após a visualização do réu, que se assustou ao visualizar a viatura e arremessou algo no solo, bem como por estar em local bastante conhecido como ponto de venda de drogas, resolveram abordar o réu. O réu estava ao lado de uma quadra de esportes e de uma Unidade Básica de Saúde. Após abordado, com o réu foi encontrado dinheiro trocado e, após apreendido o objeto arremessado, foi constatado que se tratava de 11 porções de maconha. O réu ainda admitiu que praticava o tráfico no local desde as 8 horas da manhã e ainda indicou o local onde estava o restante da droga apreendida, qual seja, uma arquibancada, onde encontraram as 11 porções de cocaína (v. mídia).

O réu, interrogado na fase policial, permaneceu em silêncio (fls. 11). Em Juízo, negou a acusação. Disse que foi ao local apenas para comprar droga. Foi ao local com R\$ 330,00 em dinheiro e, após comprar 11 porções de maconha, ficou com R\$ 225,00 que foram apreendidos. Admite que realmente jogou ao solo, quando viu a aproximação dos guardas, as 11 porções que tinha adquirido, porém, nega que indicou aos guardas onde estavam as 11 porções de cocaína. A cocaína foi encontrada na arquibancada pelos guardas, no local onde estava o traficante, que se escondeu quando da aproximação dos guardas. Nega que tenha dito aos guardas que vendia drogas. Trabalhava como servente (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o acusado era realmente o proprietário da droga apreendida, e que se destinaria a consumo de terceiros, ainda que não tenha sido flagrado negociando a venda do entorpecente com qualquer pessoa.

Os guardas civis municipais narraram de forma firme e harmônica que estavam em patrulha pelo local dos fatos, e que o réu agiu de modo suspeito, ao jogar uma sacola no chão e ficar nervoso com a aproximação da viatura.

Narraram ainda os guardas que com o réu foram encontrados R\$ 225,00 (duzentos e cinquenta reais) e que, na sacola arremessada ao solo pelo réu havia 11 porções de maconha, tendo sido ainda o próprio réu quem indicou o local onde estavam as demais porções de cocaína apreendida, cuja propriedade foi admitida pelo réu, que ainda confessou informalmente aos guardas que praticava o tráfico desde o período da manhã.

O réu, porém, embora tenha admitido que realmente jogou ao chão as porções de maconha e que estava na posse dos R\$ 225,00 apreendidos, alega que foi ao local só para comprar droga para uso próprio, e que a cocaína apreendida era do traficante que lhe vendeu a maconha.

Porém, considerando que a versão do réu não foi comprovada por qualquer outra prova dos autos, e que os guardas confirmaram que somente o réu estava no local, o qual é bastante conhecido como ponto de venda de drogas, e foi visto dispensar droga e indicou o local onde estava escondido o restante do entorpecente apreendido, bem como estava na posse de dinheiro trocado e ainda admitiu informalmente o tráfico, conclui-se que efetivamente praticava tal atividade ilícita, notadamente porque deixou de comprovar, de forma idônea, o exercício de atividade remunerada lícita ou ao menos a origem do dinheiro que trazia consigo.

Importante ainda observar que “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores

quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de policiais e guardas para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009).

A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Coeso testemunho dos policiais militares - Validade - Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório - Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas - Tráfico caracterizado - Condenação mantida - PENA - redutor no patamar máximo - necessidade - Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto - Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação 0000529-77.2015.8.26.0621 - Relator(a) Desembargador(a) Newton Neves - d.j. 20.02.2018).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP - Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 - Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira - d.j. 05.12.2017).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROVA ORAL INCRIMINADORA - A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES - O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENHIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA PENAL INALTERADA - REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 - Relator(a) Desembargador(a) Euvaldo Chaib - d.j. 14.11.2017).

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007).

"PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto" (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652).

"PROVA - Depoimento de policial - Validade - Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado - Eficiência - Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva - Ocorrência - Apelação provida parcialmente" (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 - São Paulo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator: René Nunes - 28.02.07 - M.V. - Voto n. 10.200).

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, porém tal circunstância atenuante não tem o condão de fazer com que a pena seja reduzida aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, inicialmente observo que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, notadamente a fração a ser aplicada, deve observar as diretrizes previstas no art. 42 da mesma lei, que impõe seja considerado, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Neste sentido:

"O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 3. Não se trata de violação ao princípio do non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-base, enquanto no último momento do sistema trifásico os mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a fração de redução a ser aplicada em razão da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antitóxicos. (...) 6. Ordem denegada." (STJ - HC n.º 165800/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje. 15.03.2012).

Assim, levando em conta que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, também não havendo provas de que integre organização criminosa, reduzo as penas acima indicadas em 2/3 (dois terços), totalizando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do artigo 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com

protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito “erga omnes”, cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante “o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”. Ponderou também que “a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal; as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero”.

Assim sendo, analisando o caso concreto, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos

do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime. Destaco que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente sã, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu VITOR ISAAC DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no artigo 33, caput, c.c. § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, por força da decisão proferida pelo STJ no HC nº 596.603 SP (2020/0170612-1), podendo recorrer em liberdade diante da primariedade.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita."

Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito que CONCORDAVA com a r. sentença. Pelo Defensor foi informado que se manifestará acerca de eventual interposição de recurso no prazo legal. Por fim, o MM. Juiz de Direito proferiu o seguinte despacho: "Aguarde-se eventual interposição de recurso pela Defesa no prazo legal. Arbitro honorários advocatícios ao Defensor nomeado em 70% da tabela OAB/Defensoria, complementado-se oportunamente. Expeça-se certidão de honorários. Com a manifestação da Defesa ou no seu silêncio, tornem os autos conclusos. Oficie-se o necessário. Saem intimados os presentes. Ante a realização da audiência por videoconferência, os participantes encontram-se impossibilitados de apor sua assinatura no presente termo. Nada mais." Eu, _____, Gabriel Ribeiro Lascane, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.